

[illegible]

PAULISTA, 2728/19/400 - DEL.POL.ITAPIRAPUÃ PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

FELIPE AUGUSTO DIAS RICARDO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FLÁVIA SNAIDER RIBEIRO

Vistos.

## I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em desfavor de AMAURI PALHANO DOS SANTOS e FELIPE AUGUSTO DIAS RICARDO, ambos qualificados nos autos, em decorrência da suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia (fls. 249/250), em data de 27 de julho de 2019, por volta das 18 horas e 40 minutos, na Rua Olímpio Pinto de Oliveira, Centro, na cidade de Itapirapuã Paulista e Comarca de Apiaí, AMAURI PALHANO DOS SANTOS e FELIPE AUGUSTO DIAS RICARDO, ambos agindo em conjunto e com unidade de desígnios, mantinham em depósito, para fins de comércio ilícito, 25 (vinte e cinco) epperndorf's de cocaína, destinados à venda e à entrega de terceiros.

De acordo com o Ministério Público: "Segundo se apurou, AMAURI entregou a FELIPE substâncias entorpecentes para que este realizasse a venda para terceiros. Arrependido do ato ilícito, FELIPE procurou às autoridades policiais para confessar o delito e informou o local em que as drogas estavam escondidas. Os policiais militares fizeram buscas no local indicado pelo denunciado FELIPE, uma antiga oficina de automóvel desativada próxima à residência do denunciado AMAURI, sendo que localizaram, entre o portão e o muro, uma sacola plástica contendo um embrulho de papel, no qual continham as 25 porções de cocaína. O papel utilizado para o embrulho era uma carta de cobrança em nome de Lucimara Dias, mãe do denunciado FELIPE (fls. 109/110). Durante a abordagem fora apreendido o aparelho telefônico de FELIPE e, mediante acesso autorizado pelo denunciado e posteriormente deferido por decisão judicial (fls. 128/129), a autoridade policial visualizou as conversas entre os denunciados que evidenciam a prática da mercancia ilícita. As circunstâncias da apreensão, a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como as conversas contidas no celular apreendido evidenciam que os denunciados realizam o tráfico ilícito de entorpecentes".

Acompanhou a denúncia o inquérito policial, no âmbito do qual foram encadernadas, entre outras, as seguintes peças: auto de prisão em flagrante (fl. 01), termos de declarações (fls. 02, 03, 04, 05, 160, 162 e 172/174), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 19), boletins de ocorrência (fls. 20/22 e 23/25), auto de exibição e apreensão (fls. 26/29), laudo pericial do local dos fatos (fls. 112/113), laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 163/166), laudos periciais de dados telefônicos (fls. 213/218 e 219/227), além do Relatório lavrado pela Autoridade Policial (fls. 241/244).

Decisão de fls. 66/72 concedeu liberdade provisória a ambos os acusados mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Devidamente notificados, ambos os Réus apresentaram suas Defesas Preliminares (fls. 318/330 e 333/335).

A denúncia foi recebida em 17 de março de 2021, através da decisão de fls. 441/444, oportunidade em que foi designada Audiência de Instrução e Julgamento.

Em Audiência de Instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, bem como realizado o interrogatório dos Réus (fls. 566/567).

Sobrevieram as alegações finais do Ministério Público, na forma de memoriais, em resumo, pleiteando a condenação de AMAURI nos termos da denúncia, e a aplicação do instituto previsto no art. 15 do Código Penal em favor do acusado FELIPE (fls. 572/582). A Defesa Técnica de FELIPE, por sua vez, pleiteou, em síntese, a absolvição do Réu e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 595/614). Por fim, a Defesa Técnica de AMAURI pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fls. 615/628).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório, no essencial. Passo a fundamentar e a decidir.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

A Defesa Técnica do acusado AMAURI suscitou a nulidade do feito alegando ter havido a preparação do flagrante por parte dos policiais militares, circunstância que, nos termos do Enunciado de Súmula nº 145 do c. Superior Tribunal de Justiça, levaria à ilegalidade de sua prisão em flagrante ante a configuração de crime impossível (CP, art. 17).

Ocorre que, da análise dos elementos de prova coligidos aos autos, verifica-se não ter havido a circunstância aduzida pela Defesa. O crime de tráfico, como sabido, é de natureza permanente, e tão somente pelo transporte e posse das drogas, autorizado está o flagrante. Assim, não há como confundir o alegado flagrante preparado, que se caracteriza pela indução do agente à sua prática, com a ocorrência de um flagrante esperado, o qual, no caso, tratou-se de mera confirmação das negociações de venda travadas entre os corréus através de aplicativo de troca instantânea de mensagens.

Vale destacar que o acusado FELIPE afirmou, em sede policial e em Juízo, que recebeu as drogas do corréu AMAURI, com quem trocava mensagens no celular, para posteriormente vendê-las a eventuais usuários, não se verificando, assim, que os policiais teriam induzido os Réus à prática do delito, o que afasta a alegação de que se tratou de flagrante preparado. Vale ressaltar, ainda, que nenhum elemento concreto foi trazido aos autos pela Defesa Técnica capaz de afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Alegação de ocorrência de flagrante preparado. Registre-se que, no flagrante preparado, a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível; ao passo que no flagrante forjado a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do flagrante esperado, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão” (HC n. 307.775/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/03/2015).”.  
(AgRg no HC 684.229/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade alegada pela Defesa Técnica.

Presentes as condições da ação e inexistindo outras questões preliminares e/ou prejudiciais a serem dirimidas, passo à análise de mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos através do auto de prisão em flagrante de fl. 01, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 19, dos boletins de ocorrência de fls. 20/22 e 23/25, do auto de exibição e apreensão de fls. 26/29, do laudo pericial do local dos fatos de fls. 112/113, do laudo definitivo de exame químico-toxicológico de fls. 163/166 – no qual fora detectada a presença da substância entorpecente cocaína –, bem como a partir das provas orais colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria também é inconteste.

Com efeito, em seu depoimento em Juízo, a testemunha Aguilado Domingues da Cruz, policial militar, narrou, sob compromisso legal, confirmando o quanto narrado em sede policial (fl. 02), que, na data dos fatos, estava de plantão, quando Felipe procurou a viatura e informou que alguém havia jogado uma sacolinha dentro de um quintal, e que ele teria verificado a existência de pinos de cocaína dentro; que, posteriormente, foram até o local informado e encontraram a sacola; que o local ficava nos fundos de um “lava rápido”, de propriedade de AMAURI; que após verificar a sacola, constatou que, além das drogas, havia um boleto de conta em nome da mãe de FELIPE; que, como o policial, conhecia a família deste último e perguntou para ele como seria o nome completo de sua genitora; que, após FELIPE dizer “Lucimara Dias”, pediu para que este o acompanha até a Delegacia para apurar os fatos; que após FELIPE saber disso, ficou apavorado, e falou que a droga era de AMAURI, e que, dias atrás, AMAURI lhe entregou a droga para que ele vendesse em troca de um valor em dinheiro; que FELIPE mostrou as mensagens trocadas com AMAURI confirmado sua versão; que AMAURI mandava mensagens para FELIPE e, de imediato, as apagava, para que não existissem provas contra a sua pessoa; que as mensagens eram para FELIPE levasse as drogas até o “lava rápido”; que orientou FELIPE a fazer um “print” da conversa para esclarecer a história na Delegacia; que, na Delegacia, o Delegado tomou as medidas cabíveis; que FELIPE é declarado usuário de drogas; que o nome de ambos os acusados eram informados por denúncias anônimas, que noticiaram que a oficina era um ponto de tráfico; que, porém, não há provas concreta, sobre a atuação no tráfico de drogas; que a cooperação de FELIPE foi essencial para que os policiais desvendassem os fatos.

Em sentido semelhante, foi o depoimento da testemunha Joaquim Augusto Marques, também policial militar, que relatou, sob compromisso legal, confirmando seu relato na primeira fase da persecução penal (fl. 03), que, na data dos fatos, FELIPE procurou o destacamento e contou aos policiais que AMAURI teria deixado um pacote com drogas entre o muro e o portão de uma oficina que estaria desativada; que ele e seu colega de farda deslocaram-se até o local informado juntamente com FELIPE; que após localizarem a sacola, verificaram que dentro havia vinte e cinco pinos de cocaína enrolados dentro de um papel; que FELIPE foi indagado de como ele sabia que havia drogas dentro da sacola, sendo que, segundo sua versão inicial, ele somente teria visto um indivíduo colocando uma sacola naquele local; que, então, FELIPE confessou que teria sido ele mesmo que tinha deixado lá.; que, após ser conduzido para a Delegacia, abriram e viram que o papel que embalava as drogas era um informativo do Serasa constando o nome da mãe de FELIPE; que, como se trata de cidade pequena, os policiais já sabiam que se tratava da genitora do acusado; que, após ser indagado sobre os fatos, FELIPE confessou que AMAURI o teria no comércio de drogas, porém teria se arrependido e ficado com medo de devolver as drogas para AMAURI; que FELIPE disse que tinha mensagens trocadas sobre isso com AMAURI e mostrou aos policiais; que, durante as conversas, AMAURI sempre apagava as

mensagens, e, no final, AMAURI disse para FELIPE ir à oficina e entregar as drogas; que, assim, os policiais se deslocaram para a oficina e deram vós de prisão para ambos; que vieram até Apiaí para registrar a ocorrência; que, ambos eram conhecidos criminalmente por brigas na rua e FELIPE, na época, respondia por algum crime no estado do Paraná; que o local em que AMAURI foi preso já era suspeito, uma vez que vários usuários lá frequentam o local; que existem várias “denúncias” em face de AMAURI noticiando que ele se vale de sua função de motorista do SAMU para transportar coisas ilícitas até a cidade.

Já a testemunha protegida 1, ouvida nos termos do Provimento CG nº 32/2000, afirmou, em Juízo, sob compromisso legal, que não conhece FELIPE e que conhece AMAURI de vista; que tem conhecimento de que AMAURI vendida drogas em uma oficina porque tem colegas usuários que lhe contara; que não sabe precisar qual oficina seria essa.

Por sua vez, a testemunha protegida 2, também ouvida nos termos do Provimento CG nº 32/2000, afirmou, em Juízo, sob compromisso legal, que conhece os réus de passagem; que ouviu comentários de terceiros no sentido de que os dois tinham envolvimento com drogas, mas nunca presenciou isso; que seu filho já foi usuário de drogas e lhe contou que FELIPE usava drogas; que sabe que AMAURI vendida drogas pelos comentários da rapaziada da cidade.

Por seu turno, o Réu FELIPE AUGUSTO DIAS RICARDO, afirmou, em seu interrogatório em Juízo, que a todo o momento cooperou com os policiais e sempre confirmou que as drogas eram de AMAURI; que não faz uso de nenhum tipo de droga; que pegou as drogas no sábado e os fatos ocorreram na segunda-feira seguinte, ou seja, dois dias depois; que não fez nenhuma venda porque se arrependeu; que AMAURI lhe procurou para fazer as vendas, mas já havia se arrependido e comunicado a AMAURI; que AMAURI lhe disse para deixar as drogas no local em que foram apreendidas; que, após deixá-las, procurou a Polícia para relatar o ocorrido; que não foi porque os policiais viram o nome de sua genitora no papel que embalava as drogas que resolveu falar; que desde o começo disse aos policiais que as drogas eram de AMAURI; que mostrou aos policiais as conversas em seu celular por livre espontânea vontade.

Por fim, o Réu AMAURI PALHANO DOS SANTOS negou a prática dos fatos narrados na denúncia. Afirmou que não sabe a procedência das drogas apreendidas nos autos; que foi autuado quando estava trabalhando sem saber o que estava acontecendo; que não faz uso de drogas; que conhece o local onde foi achada a droga, mas não tem qualquer vínculo com o espaço; que conhece FELIPE, mas não por causa de drogas; que neste dia somente trocou mensagens com FELIPE, pois ele queria emprestar o carro para fazer uma mudança.

Primeiramente, há que se ressaltar que, no que tange ao depoimento de policiais, civis e militares, não há dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que, no desempenho de suas atuações, agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o c. Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP,

rel. Min. Celso de Mello).

O c. Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

No caso em apreço, os depoimentos dos policiais militares foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória apta a sustentar um decreto condenatório. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais, ouvidos em Juízo, estivessem tentando incriminar falsamente os Réus, atribuindo-lhes o falso cometimento de um delito.

Embora o acusado AMAURI negue qualquer vinculação com as drogas apreendidas, as provas constantes dos autos apontam em sentido oposto.

Isso porque os policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos Réus narraram, tanto em solo policial quanto em Juízo, de forma harmônica e coerente, o envolvimento dos Réus com a traficância, como pode ser observado dos depoimentos anteriormente transcritos, bem como daqueles constantes das fls. 02 e 03 dos autos.

Destaca-se que os agentes públicos afirmaram, em Juízo, sob compromisso legal, que somente encontraram as porções da droga apreendida no presente feito (fls. 26/27) após a comunicação feita pelo acusado FELIPE, o qual relatou que, após recebê-las do Réu AMAURI, desistiu de vendê-las e procurou a Polícia. Ademais, os policiais relataram a existência de diversas “denúncias anônimas” prévias noticiando a mercancia ilícita por parte de AMAURI na cidade de Itapirapuã Paulista, o que foi corroborado pelos relatos prestados pelas testemunhas protegidas ouvidas em Juízo.

Anote-se que a quantidade (25 porções de cocaína, pesando aproximadamente 19 gramas) e a forma de acondicionamento das drogas (em porções homogêneas e individuais para pronta venda) indicam a destinação para o tráfico, bem como as circunstâncias do encontro das substâncias entorpecentes – dentro de uma sacola escondida em um terreno, envoltas em documento que continha o nome da genitora do acusado FELIPE –, além do que já se expôs, geram a convicção da posse voltada para o comércio e não a finalidade para o uso próprio.

Nessa mesma ordem de ideias, conforme trecho do v. Acórdão proferido na Apelação nº 0000926-20.2016.8.26.0616, “[p]or outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda” (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

Ainda, em consonância com a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de que o Réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia ilícita, especialmente porque o tipo penal é misto alternativo e a prática de qualquer conduta do núcleo do tipo caracteriza do delito.

Por outro lado, no caso concreto, é possível o reconhecimento do instituto da desistência voluntária em favor do acusado FELIPE.

Como cediço, nos termos do art. 15 do Código Penal, a desistência voluntária ocorre

quando o agente, por manifestação exclusiva do seu querer, desiste de prosseguir na execução do crime. Assim, o agente abandona o intento quando ainda tinha atos executórios para serem praticados.

In casu, apesar de o acusado FELIPE ter mantido em depósito, ainda que por curto espaço de tempo, as porções da droga – o que, em tese, já caracteriza o tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 –, as circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de não ter perpetuado os atos executórios que pretendia inicialmente e ter voluntariamente procurado a Polícia após receber os entorpecentes, sem ter realizado qualquer ato de mercancia, bem como indicado o local onde as drogas estavam armazenadas, permitem a aplicação do instituto em referência em seu favor, afastando-se, inclusive, sua responsabilização criminal. Nesse ponto, valho-me da argumentação apresentada pelo órgão acusatório como razões de decidir, no seguinte sentido: “Em que pese a comprovação da materialidade e autoria também com relação ao réu FELIPE, verifico cabível, quanto a ele, o instituto da desistência voluntária. O art. 15 do Código Penal prevê que o agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Segundo Guilherme de Souza Nucci a desistência voluntária consiste na desistência no prosseguimento dos atos executório do crime, feita de modo voluntário. Ensina o doutrinador que no caso da desistência, exige-se apenas a voluntariedade, mas não a espontaneidade: se o agente deixar de prosseguir na trajetória criminosa porque se arrependeu do que vinha fazendo, terá agido de modo voluntário e espontâneo, embora não seja necessário este último requisito para configurar a excludente (Código Penal Comentado, Editora Forense, 17ª edição, p. 123/124) (...) Exatamente este o caso de FELIPE, eis que, recebendo a substância entorpecente para fins de tráfico, antes de qualquer ato de comercialização, desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime e acionou a polícia militar indicando a localização da droga. Em que pese a conduta de 'manter em depósito' já possa configurar o delito de tráfico de drogas, as circunstâncias do presente caso permitem a incidência do instituto da desistência voluntária, eis que FELIPE voluntariamente interrompeu os demais atos executórios, acionou a polícia e indicou o local das substâncias entorpecentes. No caso dos autos, inexistindo crime anterior praticado por FELIPE, não há que se falar em desclassificação ou condenação por outro delito, motivo pelo qual, com relação a ele, requeiro a improcedência da ação” (fls. 579/580).

Por outro lado, segundo que se extrai dos autos, restou demonstrado, além de qualquer dúvida razoável, que o acusado AMAURI PALHANO DOS SANTOS mantinha em depósito 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, para fins de comércio ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por sua vez, deixo de reconhecer, no caso concreto, a causa de aumento de pena narrada na peça acusatória (Lei nº 11.343/06, art. 40, inciso III), tendo em vista que, ao longo da instrução processual, não foram reunidas fontes de prova suficientes que revelassem, para além de qualquer dúvida razoável, as circunstâncias mais gravosas previstas no referido dispositivo legal, sendo certo que, de acordo com a doutrina especializada, “a justificativa para a existência desta majorante diz respeito à enorme facilidade de disseminação do consumo de drogas nesses locais em virtude da maior concentração de pessoas, o que acaba por representar maior risco à saúde pública”.

Por fim, reconheço a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em benefício do acusado AMAURI, considerando não apenas a pouca quantidade da droga apreendida, mas sobretudo diante da ausência de comprovação de que o Réu se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, bem como considerando o fato de que não possui condenações criminais pretéritas nem está sendo processado por outros crimes (fl. 558).

Conforme a Teoria da Indiciariade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela

doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao Réu trazer aos autos ao menos a dúvida fundada quanto à presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o Réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude. Além disso, inexistem nos autos qualquer elemento que aponte que ele agiu de forma justificada. Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da Teoria Normativa Pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes. Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa. Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Réu AMAURI PALHANO DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena do acusado AMAURI PALHANO DOS SANTOS, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CFB, art. 5º, inciso XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais, razão pela qual a presente circunstância judicial não poderá ser considerada negativa (fl. 558); c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do Réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: não há motivos concretos para serem consideradas negativas. Assim, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que a pena intermediária permanece inalterada.

Na terceira fase, verifica-se a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sobretudo diante da ausência de comprovação de que o Réu se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, bem como considerando o fato de que não possui anotações penais pretéritas. Ademais, considerando a baixa quantidade de entorpecente apreendida, diminuo a pena intermediária em 2/3 (dois terços) e fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em atendimento ao disposto no art. 49, § 1º, do Código Penal, fixo valor do dia-



multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do Réu.

Impede salientar, por fim, que o c. Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que são inconstitucionais as previsões da Lei nº 11.343/06 que impõem a adoção obrigatória do regime inicial fechado e a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo ser observadas as regras do Código Penal quanto ao ponto.

Assim, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena, a primariedade do Réu e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime ABERTO para início de cumprimento da pena, mediante o cumprimento das seguintes condições: a) permanecer recolhido em sua residência nos finais de semana, feriado e dias de folga, bem como nos demais dias entre as 22h00min e às 06h00min; b) não se ausentar da Comarca sem prévia e expressa autorização do Juízo; e c) comparecer mensalmente a Juízo, para informar e justificar suas atividades.

Considerando, entretanto, que o Réu preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, eis que a reprimenda aplicada não é superior a 04 (quatro) anos; que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e que não é o Réu reincidente, SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no montante de 01 (um) salário-mínimo, o qual deverá ser destinado a uma instituição pública ou privada de assistência social indicada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 45, § 1º), e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal, haja vista que tais sanções afiguram-se de todo suficiente para prevenção e reprovação do delito perpetrado.

Em razão da substituição operada, deixo de suspender a execução da pena, nos termos do disposto no art. 77, inciso III, do Código Penal.

### III - DISPOSITIVO

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para:

III.I. CONDENAR o Réu AMAURI PALHANO DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal. SUBSTITUO a sanção privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas de direitos (CP, art. 44, § 2º), aplicando a PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA no montante de 01 (um) salário-mínimo, o qual deverá ser destinado a uma instituição pública ou privada de assistência social indicada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais (CP, art. 45, § 1º), e a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na razão de tempo prevista no art. 46, § 3º, do Código Penal; e

III.II. ABSOLVER o Réu FELIPE AUGUSTO DIAS RICARDO, qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos do art. 15 do Código Penal c/c art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

### IV- DISPOSIÇÕES FINAIS

IV.I. CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

IV.II. Conforme a determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva do Réu AMAURI PALHANO DOS SANTOS por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como

considerando o fato de que foi condenado à pena a ser cumprida em regime inicial aberto, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos.

IV.III. Considerando a demonstração de que o numerário apreendido é produto do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal c/c art. 63, inciso I, da Lei nº 11.343/06, como efeito secundário da condenação, DECRETO o perdimento em favor da União dos valores apreendidos às fls. 26/27. Com o trânsito em julgado da presente sentença, PROCEDA-SE a reversão da quantia em favor do FUNAD.

IV.IV. DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

IV.V. COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intímem-se os Réus para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos conclusos. para declaração da extinção da pena.

IV.VI. DETERMINO a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (Lei nº 11.343/06, art. 72), caso a providência já não tenha sido adotada.

IV.VII. Fixo os honorários advocatícios do(s) patrono(s) de acordo com a tabela do convênio celebrado entre a OAB/DPE. Expeça(m)-se certidão(ões) a qual ficará disponível através do sistema SAJ para que o advogado, após a devida conferência, providencie sua impressão.

IV.VIII. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

IV.IX. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intímem-se.

Apiai, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA